

1506004-08.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA A DESPEITO DE PLEITO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506004-08.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506004-08.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068898/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 23554139 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2068898 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANASTACIO PEREIRA FERNANDES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Vistos.

ABNER HENRIQUE VICENTE FERREIRA, qualificado às fls. 29, e MARCOS ANASTÁCIO PEREIRA FERNANDES, qualificado às fls. 28, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tudo na forma do artigo 71, do Código Penal, porque segundo o Ministério Público, no dia 11 de março de 2022, por volta das 17h00min, no interior da Estação de Metrô Penha, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito deles, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, o aparelho celular Samsung J7, avaliado em R\$ 800,00 pertencente à vítima João V. C. S., e o aparelho celular Samsung M31, avaliado em R\$ 2.000,00, pertencente à vítima João V. F. da C..

Apurou-se que, no dia dos fatos, os denunciados deliberaram em assaltar vítimas adolescentes no interior da Estação de Metrô Penha.

As vítimas João V. C. S. e João V. F. da C. (ambos com 15 anos de idade) estavam saindo juntos da Estação Penha do Metrô, quando então foram abordados pelos denunciados.

O denunciado Marcos lhes disse que o aparelho celular de sua filha havia sido subtraído e que gostaria que as vítimas mostrassem os respectivos celulares para confirmar que não foram eles quem o subtraiu.

Assim, as vítimas mostraram os respectivos aparelhos e guardaram no bolso. , Marcos, contudo, solicitou que os mostrassem novamente e, nesse momento, Abner subtraiu ambos os aparelhos e disse que estavam armados e que se não entrassem no ônibus (que estava parado nas proximidades) iriam matá-los.

Subjugadas com a grave ameaça, as vítimas embarcaram em um ônibus e deixaram o local.

Apurou-se, ainda, que, no dia 11 de março de 2022, por volta das 17h, no Terminal Penha (ônibus), nesta cidade e comarca de São Paulo, após a prática dos roubos descritos acima, os denunciados, previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito deles, mediante violência e grave ameaça simulando portar arma de fogo, o aparelho celular Motorola, avaliado em R\$ 600,00, pertencente à vítima Paulo V. N. S. (16 anos de idade), somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ocorre que, após a prática dos roubos mencionados acima, levando a diante o propósito de praticar roubos, os denunciados deliberaram em assaltar outra vítima. Por sua vez, a vítima Paulo (16 anos de idade) estava no Terminal Penha (ônibus) quando então foi abordada pelos denunciados que lhe perguntaram se tinha visto alguém com um Iphone, pedindo-lhe para que mostrasse seu aparelho celular.

A vítima, contudo, os ignorou, não atendeu ao pedido e embarcou em um coletivo.

Em seguida, os denunciados foram no encalço da vítima e embarcaram no mesmo coletivo, dentro do qual foram em sua direção, tentando dizer algo, que igualmente foi ignorado.

Assim, a vítima estava no interior do coletivo com o celular na mão, o denunciado Abner foi em sua direção e tentou tirar o celular (da mão da vítima), dando-lhe um empurrão. Contudo, não conseguiu pegar o aparelho, pois a vítima resistiu.

Ato contínuo, a vítima reagiu e iniciou uma luta corporal com o denunciado Abner, ocasião em que o denunciado Marcos disse à vítima que estava armado e ordenou que lhe entregasse imediatamente o aparelho celular.

Em meio à contenda, o motorista do coletivo parou o veículo no semáforo a uma viatura da Polícia Militar e comunicou o ocorrido aos policiais. Deste modo, os policiais desembarcaram e adentraram no coletivo.

Em seguida, cientificarem-se dos fatos, procederam à abordagem dos denunciados. Com o denunciado Abner foram localizados os aparelhos celulares das vítimas João (1) e João (2), além da quantia de R\$ 50,00. Indagado, Abner não soube explicar a origem de ambos.

Em revista pessoal, encontraram com Marcos um aparelho celular e a quantia de R\$ 116,00. Indagado, disse que o celular lhe pertencia. Entretanto, este aparelho tocou e era o pai da vítima João V. F. C., o qual informou aos policiais que o celular era produto de roubo.

Desse modo, os policiais apuraram que um dos dois aparelhos celulares encontrados com Abner pertencia à vítima João V. C. S. Por fim, os policiais deram voz de prisão em flagrante delito aos denunciados e os conduziram ao Distrito Policial. O segundo delito, em face da vítima Paulo, segundo o Parquet, somente não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, consistente na reação da vítima, a qual entrou em luta corporal até a chegada e abordagem dos policiais militares.

As vítimas João (1) e João (2) reconheceram, sem resquício de dúvidas, os denunciados como os autores do delito, conforme auto de reconhecimento pessoal positivo de fls. 21 e 22.

Os objetos encontrados com os denunciados foram arrecadados, conforme autos de fls.

34 e 35.

Os aparelhos celulares das vítimas foram avaliados (fls. 40/41) e restituídos (fls. 42/43, 44/45 e 46).

Interrogados, os denunciados mantiveram-se em silêncio.

Folha de antecedentes do réu Marcos juntada às fls. 101/115 e 166/181 e certidões às fls. 96/100.

Folha de antecedentes do réu Abner juntada às fls. 116/117 e 163/164.

Recebida a denúncia em 25 de março de 2022 (fls. 189/191), designada audiência de instrução, debates e julgamento.

O réu Abner foi citado (fls. 216), apresentou resposta à acusação às fls. 225.

O réu Marcos foi citado (fls. 219), apresentou resposta à acusação às fls. 225.

Na audiência (fls. 228/229) foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum.

Por decisão de fls. 244/245, designada nova audiência de instrução, debates e julgamento para oitiva das vítimas e interrogatório dos réus.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus referente aos roubos em face das vítimas João V. C. S. e João V. F. da C. Pugnou pela aplicação da pena acima do mínimo legal e pelo aumento referente ao concurso de agentes. Em relação ao réu Marcos, pela agravante da reincidência, e, para ambos os réus, a atenuante da confissão. Na fase final, pelo aumento, já que os crimes foram praticados em concurso formal. Regime inicial o fechado. O Parquet foi pela absolvição da tentativa de roubo praticado contra a vítima Paulo V. N. S. A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição por atipicidade em relação ao suposto roubo tentado. Em relação aos roubos consumados, requereu aplicação de pena mínima, aplicação da atenuante da confissão e em relação ao réu Marcos a compensação com a agravante da reincidência, por fim a aplicação do artigo 71 do CP, majorando-se a pena na fração mínima. A fixação de regime inicial diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

Relatado.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva dos três delitos restou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07), boletim de ocorrência de fls. 08/12, auto de reconhecimento de pessoa de fls. 21/22, bem como pela prova oral colhida, especialmente sob o crivo do contraditório.

A autoria mostrou-se indubitosa em relação aos acusados, pelas mesmas provas, para os três crimes deste feito.

Transcrevo, então, os depoimentos colhidos em audiência:

JOÃO V. F. DA C., vítima (menor de idade), ouvido por depoimento especial, disse "que tem 16 anos. Estava eu e o meu amigo Joao Victor, nós fazemos o técnico e o médio junto. Saímos e estávamos voltando. Na volta, pegamos o metrô - estação Vila Carrão para Penha. Na Penha, descemos a escada. O ônibus dele fica para frente. Eu ainda não sabia o ônibus que pegava, aí eu ia com meu pai. Logo a frente, tem um ponto de ônibus. Nesse ponto, o assaltante apareceu. O primeiro apareceu e falou que a filha dele tinha sido roubada e pediu para nos mostrarmos o celular. Mostrei e guardei de volta. Eu guardava no bolso, meu amigo, na bolsa, dentro do estojo. Mostrei de novo. Eu mostrei, veio um outro por trás, pegou o do meu amigo e o meu. Falou para entrarmos num ônibus e irmos embora. Na hora, fiquei nervoso e falei que ia para o outro lado. Ele falou "entra no ônibus, se você não entrar, vou te matar". Segui meu amigo. Quando o ônibus saiu, vi pela janela que meu pai estava lá. Minha preocupação era o meu pai, porque, um tempo atrás, eu tinha esquecido de avisar que cheguei na escola, uns dias atrás. Porque estava sem bateria. Meu pai, nesse dia passado, foi parar na escola, para me procurar. Então, por esse fato passado, eu fiquei mal, me senti mal. Fui para a casa do meu amigo. Lá, a mãe dele me deu o telefone. Eu estava nervoso e me confundi, liguei para o meu celular. Ele estava na polícia. Quando a gente saiu, ele tentou roubar outro menino que estava dentro do ônibus já, mas ele empurrou e não conseguiram roubar. A polícia chegou e prendeu eles. O roubo foi umas 17h. Foi mais ou menos 11/03. Acho que o de trás estava de boné. É bem improvável que eu consiga reconhecê-los. Não me lembro de ele falar que estava armado, mas deu a entender que estava. Ele deu a entender apenas. E disse que iria me matar. Não cheguei a ver nenhuma coisa que se assemelhasse a

uma arma. Na delegacia, eu fiz o reconhecimento dele, naquele momento, naquela época, eu consegui reconhecer. Hoje em dia, eu não conseguiria reconhecer essas pessoas”.

JOÃO V. C. S., vítima (menor de idade), ouvido por depoimento especial, disse “que tem 16 anos. Naquele dia, eu e o meu amigo estávamos saindo do metrô Penha. Eu ia pegar ônibus e o meu colega, iria com o pai. Mais para frente, vi que um cara estava olhado para mim. Abordou a mim e ao João. Ele perguntou se a gente estava com celular, porque a filha dele havia sido assaltada e roubaram um Iphone dela. Ele falou para mostrar. Eu falei que não tinha iphone, Ele falou que era melhor mostrar, porque ele estava armado e podia fazer alguma coisa contra mim. Aí, um cara chegou lá atrás, um parceiro dele e foi recolhendo o celular. Disse para a gente entrar no ônibus, o meu colega ia para o pai dele. Aí, ele falou que era para o meu colega entrar no ônibus comigo, senão ele iria matar a gente. Ele não chegou a mostrar um simulacro. Entramos no ônibus, eu e meu amigo, fomos para minha casa e falamos com a minha mãe. Depois fomos para a DP. O João ligou da minha casa para o celular dele, falou com uma policial. E ela falou que estava na Delegacia. Fomos para lá também. Na delegacia, fiz reconhecimento dessas pessoas. Hoje, eu conseguiria reconhecer quem são eles”.

PAULO V. N. S., vítima (menor de idade), ouvido por depoimento especial, disse “que estava voltando da ETEC, na estação da Penha há um ônibus que passa direto na minha rua. Desço a estação da Penha. Aí, dois caras me abordaram, Abner e Marcos, o Marcos me perguntou se eu conhecia algum lugar. O outro me puxou pela camisa. Ele falou que roubaram o iphone de alguém, parente dele, se eu teria visto. Eu falei que não sabia de nada. Ele pediu para eu mostrar o meu celular. Mostrei e guardei. Eles ficaram enchendo. Eu entrei no ônibus. Deu 5 min, o Marcos ficou na frente e o Abner do meu lado. Eu derrubei o Abner na porta. Me enchi. Isso já estava uns 2 ou 3 min no percurso. Na frente, tinha acontecido uma batida. O motorista viu a polícia e a chamou. Eles fizeram a abordagem. Soube o nome deles depois, nunca os havia visto. Eu estava no canto do último banco, o Abner se sentou do meu lado e o Marcos, lá na frente. Continuaram e abordaram a mim. Eu não lembro o que falaram. Eu perdi a paciência, empurrei o que estava do meu lado. Ele não tentou reagir, o Marcos ameaçou, mas não fez nada. O Marcos falou para eu descer e andar na rua, que a gente se resolvia, que ele estava com uma arma. Como ele não fazia nada, percebi que ele estava mentindo. Quando os policiais chegaram, os dois desceram do ônibus, foram revistados. Depois, eu descii. Os policiais deram voz de prisão em flagrante, por tentativa de assalto. Ficamos até umas 7h ou 8h da noite. Fui chamado primeiro para fazer a ocorrência com a Delegada. Depois de uns 10 ou 15 min de conversa, assinei, peguei meu celular e saí fora. Não foi preciso o reconhecimento, porque estavam juntos comigo no momento da prisão. Hoje em dia, bem provavelmente eu os reconheceria. Não mostrou nada que parecia uma arma, só falou que estava armado. O Marcos chegou a segurar o celular, quando eu tirei, puxou umas duas vezes, depois eu guardei. Ele não falou para eu entregar não. Dentro do ônibus, ele falou que eu empurrei o Abner, o Marcos disse que estava armado. Não me senti ameaçado”.

Vinicius da Silva Brandão, policial militar, declarou que “sexta-feira parte da tarde, estava patrulhando próximo ao metrô, quando na Rua Demini, propriamente dito, um ônibus passando do lado da viatura passou a buzinar e acenar como se estivesse acontecendo alguma coisa no interior do coletivo. Diante dos fatos, nós desembarcamos e o motorista havia informado que estava tendo uma briga no interior do ônibus, abriu as portas, e fizemos a abordagem. Num primeiro momento foi localizado os celulares com dois rapazes, identificados como sendo os infratores, e com o terceiro quando fomos fazer a abordagem questionar o que estaria acontecendo, nos informou que estava sofrendo uma tentativa de roubo, momento que a equipe chegou. Durante a abordagem um dos celulares começou a tocar sendo o pai de uma das vítimas, foi informado que estava sendo feita a abordagem e caso conseguisse contado com o filho dele para comparecer ao Distrito Policial – 10º DP. Já pela delegacia chegou o pai juntamente com os dois adolescentes, posteriormente chegou a mãe de um deles, foi apresentado para o delegado de plantão, quando o mesmo levou os adolescentes juntamente com os pais para fazer o reconhecimento, os adolescentes reconheceram, sem sombra de dúvida, os infratores como sendo os responsáveis por

fazer o roubo, momentos antes pelo metrô penha. Na tentativa o celular ainda estava com a vítima”.

Adilson Correia Boarati, policial militar, declarou que “o primeiro fato não presenciou, pois ocorreu anteriormente. Que presenciou a abordagem. Que estava com seu parceiro, existia um subsetor que tem por obrigação tomar conta, e que estava de patrulhamento neste subsetor, no qual vinha um coletivo em sua direção, o motorista colocando a mão para fora, informou que estava ocorrendo uma briga no fundo deste coletivo. Nós descemos, efetuamos a abordagem, a princípio destes cidadãos que estavam no fundo do coletivo, colocamos todos para fora, fizemos o enquadro da abordagem como nós costumamos dizer, e começamos a fazer a revista, busca pessoal a princípio um afastado do outro. Na revista eu encontrei com os réus alguns celulares. Ao revistar o terceiro rapaz, este dizia ser vítima naquele exato momento de uma tentativa de roubo pelos dois acusados. Diante dos fatos, um dos telefones tocou que estava de posse dos réus, e estava escrito “mamãe” ou “papai” alguma coisa assim, dizendo que queria falar com meu filho, que está demorando para chegar, eu disse que era a polícia militar e nós estamos com três pessoas abordadas, a pessoa disse que este telefone é do meu filho, aí eu falei tenta entrar em contato com seu filho e vá para o 10º DP, porque nós temos duas pessoas aqui que acabaram de tentar um roubo num coletivo. Posteriormente, encaminhamos a ocorrência ao 10º DP, chegando no 10º DP compareceram algumas pessoas, pais e filhos, sendo que os filhos diziam ser vítimas destes dois rapazes, no metrô penha. Por isso que não presenciei o primeiro fato, já a tentativa de roubo, eu e meu parceiro conseguimos intervir desta forma. Estes adolescentes conversaram com o delegado de plantão e reconheceram eles, eu presenciei no distrito policial. Os acusados negavam os fatos”.

O acusado ABNER HENRIQUE VICENTE FERREIRA declarou que “participei sim de dois crimes. Dos dois menores, o outro foi só um atrito que a gente teve lá e não houve voz de assalto. O primeiro ocorreu do mesmo jeito que foi narrado na denúncia. Quero uma oportunidade de semiaberto, estou arrependido, queria me reabilitar”.

O acusado MARCOS ANASTÁCIO PEREIRA FERNANDES declarou que “confesso só primeiro, o segundo não. Aconteceu que eu estava no terminal penha, eu e Abner, passamos nesses dois moleques, perguntei a hora, depois perguntei de novo, falei que estava armado, só simulando. Meu filho estava doente. Em relação ao terceiro, estava dentro do ônibus, quem para cima dele foi o Abner. Vimos o terceiro na rua, mas não sabíamos que estava dentro assalto do segundo, não sei se o Abner deu. Na rua, nós pedimos para mostrar o celular, falei que havia uma sobrinha que tinha sido roubada, o mesmo estilo de abordagem dos outros adolescentes, para tentar pegar o celular. Eu estou arrependido”.

Pois bem.

Passo à análise dos delitos de roubo consumado (artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal).

O acervo probatório coligido aos autos traz a certeza necessária para o édito condenatório, mormente pelo depoimento das vítimas ouvidas e das testemunhas, que se mostraram harmônicos e coerentes, bem como pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07), pelo boletim de ocorrência de fls. 08/12, auto de reconhecimento da pessoa de fls. 21/22, auto de avaliação de fls. 46/47, auto de entrega de fls. 48/51, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 53/54. Além disso, os réus confessaram os delitos referente aos roubos consumados.

O cotejo probatório produzido nos autos, demonstram claramente autoria e a materialidade, pois os acusados abordaram as vítimas saindo da Estação Penha do Metrô, o acusado Marcos pediu para as vítimas mostrarem os aparelhos celulares, sob o pretexto que sua filha havia sido assaltada. Após apresentarem os celulares, o acusado Abner os subtraiu, ameaçando-os a entrarem no ônibus que estava parado, caso contrário, iria mata-los.

Desse modo, é certo que ocorreram os delitos de roubos consumados, com concurso de agentes.

Como se vê, o farto conjunto probatório conduz à condenação dos acusados, visto que estes confessaram os delitos, as duas vítimas os reconheceram na fase policial. Na fase processual, foi realizado o reconhecimento apenas com a vítima J.V.C.S.,

que reconheceu o acusado Marcos, todavia não conseguiu reconhecer o acusado Abner, o que, contudo, não enfraquece o conjunto probatório, pois os celulares foram encontrados com os réus.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a condenação. Passo à análise do delito de tentativa de roubo (artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

É importante destacar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, caput, prevê o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado irá analisar o caso e julgá-lo conforme as provas trazidas aos autos, mas terá liberdade para a sua valoração, distinguindo-se, portanto, do princípio da convicção íntima e da prova tarifada.

Conforme assinala Guilherme de Souza Nucci: "(...) a persuasão racional é o método misto, também chamado de convencimento racional, livre convencimento motivado, apreciação fundamentada, ou prova fundamentada. Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), significando permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato" (NUCCI, 2008, pag. 339).

Além disso, o art. 385 do Código de Processo Penal ensina que "Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada."

Nessa mesma esteira, segue a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA A DESPEITO DE PLEITO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro, de modo que não há falar em nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado, com fulcro no acervo fático-probatório constante dos autos, à luz do princípio da persuasão racional, reconhece a responsabilidade do réu, condenando-o nos termos da exordial acusatória. 2. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, as instâncias de origem destacaram que o paciente ostenta três condenações definitivas anteriores, as quais foram utilizadas para exasperar a pena a título de maus antecedentes no patamar de 3/5. Com efeito, a referida fração não se mostra desarrazoada para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, levando-se em consideração a existência de três condenações prévias a macular os antecedentes criminais do paciente, o que enseja uma resposta penal mais efetiva. 3. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 430803 RJ 2017/0333268-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO - ARTIGO 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - WRIT DENEGADO. 1- A decisão do Juiz não é vinculada pelas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, podendo ele condenar o réu, mesmo quando o Parquet opina pela absolvição. 2- Havendo provas para julgar o feito, condenando o réu, o Juiz não deve se atrelar à opinião do Ministério Público, quando este requer a absolvição. 3- O habeas corpus não é o meio adequado para análise de pedido de absolvição, posto que não é possível a incursão nas provas dos autos. 4- Writ denegado.

(STJ - HC: 84001 RJ 2007/0125212-3, Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA

CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 11/12/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/02/2008 p. 1)

Com base nesses fundamentos legais e jurisprudenciais, entendo diversamente do Ministério Público, para expedir decreto condenatório também pelo delito de roubo tentado.

Nesse sentido, saliento que o acervo probatório coligido aos autos traz a certeza necessária para a condenação, mormente pelo depoimento da vítima e das testemunhas, que se mostraram harmônicos e coerentes, bem como pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07), pelo boletim de ocorrência de fls. 08/12, auto de avaliação de fls. 46/47, auto de entrega de fls. 52, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 53/54. As provas produzidas demonstram claramente autoria e a materialidade, pois o acusado Marcos abordou a vítima dizendo que ela para mostrar o celular, sob o pretexto que haviam roubado o iphone de algum parente, sendo que a vítima mostrou e guardou o celular e os acusados tentaram puxá-lo por duas vezes. Esse foi o mesmíssimo modus operandi utilizado no delito anterior, que se consumou. Dois homens adultos intimidando adolescentes que retornavam da escola de metrô e constrangendo os adolescentes a mostrarem os celulares, momento em que o plano dos roubadores era pegar o aparelho e ameaçar a vítima para garantir o proveito do crime.

Isso deu certo nos roubos contra as duas primeiras vítimas.

No entanto, o terceiro adolescente, com a coragem inconsequente que a pouca idade lhe traz atuou diferentemente dos dois adolescentes anteriores.

Essa terceira vítima ignorou os roubadores e, para fugir da coação aplicada – pela superioridade numérica e pela postura insistente e ameaçadora, já que chegaram a lhe puxar a camisa – entrou no ônibus.

No entanto, isso não foi suficiente para dissuadir os réus, porque os acusados foram atrás da vítima dentro do ônibus, sendo que Marcos ficou na frente e Abner se sentou ao lado da vítima.

Evidentemente, apesar da imaturidade trazida pela adolescência, essa postura de dois homens, adultos, que perseguem um adolescente de 16 anos, foi capaz de intimidá-lo, tanto que se apressou em entrar no ônibus.

Os réus foram atrás do adolescente e o cercaram, ficando um ao seu lado no ônibus e outro, na parte da frente, por alguns minutos.

Então, como prova do temor da vítima menor de idade, que se viu encurralada, esta reagiu e empurrou o réu que estava lhe constrangendo dentro do ônibus.

Vê-se, claramente, que houve a grave ameaça o tempo inteiro, portanto.

Abner entrou no ônibus no encalço da vítima, um adolescente de 16 anos e continuou a constrangê-la, tanto que esta se viu sem opção e reagiu ao assalto.

O fato de o adolescente, em depoimento especial, ter dito que não se sentiu ameaçado é apenas prova de que sua fala foi influenciada pela imaturidade de sua menoridade, já que todos os seus atos –do adolescente –demonstram o contrário.

Tanto o adolescente sentiu medo, que se apressou para pegar o ônibus, ignorou as investidas dos roubadores, segurou fortemente o celular (tanto que, apesar de puxarem por duas vezes, não o levaram), sentou-se longe da entrada e, ao fim, já sem opção, reagiu às investidas de Abner, empurrando-o.

Quando reagiu, a ameaça dos réus, que era indireta, mas sempre presente, tornou-se pública e explícita. Nesse momento, o acusado Marcos ameaçou o adolescente e disse que estava armado.

Por sorte, o motorista do ônibus agiu e chamou os policiais, que adentraram o ônibus e evitaram a consumação do delito.

Apesar de não haver ordem de assalto, ficou evidente, para o Juízo e para o adolescente, que os réus, empregando a grave ameaça mencionada, queriam seu celular, tanto porque a abordagem foi a mesma do crime anterior, tanto porque eles puxaram o celular das mãos da vítima por duas vezes, como porque a perseguiram dentro do coletivo.

A alegação de que entraram no mesmo coletivo por coincidência é absurda, pois os fatos se deram rapidamente, o que indica a ciência dos réus sobre o ônibus em que a vítima entrou. Além disso, se fosse realmente uma coincidência, não haveria motivo

para o cerco feito pelos assaltantes dentro do ônibus contra o adolescente. Entender diversamente do explanado é fazer tábula rasa, não só da Lei Penal, mas principalmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela prioridade absoluta de seus interesses e proteção integral aos infantes.

Isso porque haveria discriminação ao terceiro adolescente, unicamente porque, em um ato de coragem insana, reagiu ao assalto e se defendeu, tratando esse adolescente com proteção estatal menor do que a conferida aos outros dois menores, contra os quais o crime se consumou.

Além disso, seria usada uma única afirmação infeliz - e desinformada - do adolescente, qual seja, a de que não se sentiu intimidado, em prejuízo de inúmeras provas em sentido contrário, de que houve intenso e fundado temor por essa vítima menor de idade.

O modus operandi foi o mesmo para as três vítimas, tal qual o desiderato dos réus, o que afasta qualquer manifestação absolutória por parte do Ministério Público ou da defesa.

Assim, o farto conjunto probatório conduz à condenação dos acusados, visto que foram presos em flagrante (fls. 07) quando da tentativa do delito.

Na fase judicial, foi realizado o reconhecimento dos acusados, no qual a vítima reconheceu o réu Marcos com certeza meridiana. Quanto ao réu Abner, como estava de boné na data dos fatos, houve dúvida, o que não descaracteriza o fato de que ambos estavam no local realizando o crime - pelas inúmeras provas apontadas.

Assim, o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, consistente na rápida intervenção policial quando da abordagem ao ônibus, impedindo a subtração.

Trata-se de tentativa, pois os réus ameaçaram a vítima para entregar o aparelho celular, contudo foram detidos antes que conseguissem inverter a posse do bem. Destarte, devidamente comprovadas a existência da tentativa do roubo qualificado pelo concurso de agentes e a atribuição de sua autoria, a deflagração dos mecanismos da responsabilidade penal é medida de rigor.

Passo, agora, à etapa da aplicação da pena.

Roubos majorados consumados

Transcrevo o dispositivo legal aplicável:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca

Os crimes foram praticados contra duas vítimas diferentes, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar. Assim, realizo apenas uma dosimetria, que valerá, isoladamente, para cada um dos dois crimes de roubo majorado mencionados na denúncia.

a) Acusado ABNER HENRIQUE VICENTE FERREIRA:

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de natureza subjetiva, verifico que a reprovabilidade da conduta do acusado está acima da média, pois praticou o delito propositamente contra estudantes adolescentes, que, por sua pouca idade, seriam pessoas mais intimidáveis e mais vulneráveis às suas investidas.

Assim, elevo a pena em 1/8 e a fixo em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. No entanto, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), todavia, ela não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal (súm 231, STJ). Assim, reduzo a pena para fixá-la em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena. No entanto, há a causa de aumento do art. 157, §2º, II, CP, pelo concurso de agentes, que proporcionou aos roubadores a segurança de que haveria um incremento da grave ameaça, perante os adolescentes, justamente pelo número de agentes maiores atuando no assalto.

Assim, a reprovabilidade da conduta é aumentada neste caso concreto, o que enseja a majoração da pena em 1/3.

Por isso, a pena resta fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, reprimenda que se aplica a cada um dos crimes de roubo praticados contra os dois adolescentes.

Sobre essa pena, ainda se aplica o aumento do concurso formal.

Isso porque, os crimes foram praticado mediante uma só ação, contra duas vítimas diferentes, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, em concurso formal próprio, ou seja, sem desígnios autônomos.

Por isso, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

b) Acusado MARCOS ANASTÁCIO PEREIRA FERNANDES:

Na primeira fase, devem ser consideradas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Destaco que o réu ostenta maus antecedentes (processo n. 0042448-86.2010.8.26.0050 - fls. 97/98), razão pela qual aumento a pena em 1/8.

Além disso, a reprovabilidade da conduta do acusado está acima da média, pois praticou o delito propositamente contra estudantes adolescentes, que, por sua pouca idade, seriam pessoas mais intimidáveis e mais vulneráveis às suas investidas.

Assim, elevo a pena em mais 1/8, havendo um aumento total em 2/8, ou seja, 1/4, na primeira fase.

A pena base fica fixada em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência (autos nº 0034478-54.2018.8.26.0050 - Fls. 97). Está presente também a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP). Dessa forma, compenso a agravante com a atenuante e mantenho a pena em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena. No entanto, há a causa de aumento do art. 157, §2º, II, CP, pelo concurso de agentes, que proporcionou aos roubadores a segurança de que haveria um incremento da grave ameaça, perante os adolescentes, justamente pelo número de agentes maiores atuando no assalto.

Assim, a reprovabilidade da conduta é aumentada neste caso concreto, o que enseja a majoração da pena em 1/3.

Por isso, a pena resta fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, reprimenda que se aplica a cada um dos crimes de roubo praticados contra os dois adolescentes.

Sobre essa pena, ainda se aplica o aumento do concurso formal.

Isso porque, os crimes foram praticado mediante uma só ação, contra duas vítimas diferentes, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, em concurso formal próprio, ou seja, sem desígnios autônomos.

Por isso, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

da tentativa de Roubo majorado

a) Acusado ABNER HENRIQUE VICENTE FERREIRA:

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de natureza subjetiva, verifico que a reprovabilidade da conduta do acusado está acima da média, pois praticou o delito propositalmente contra estudante adolescente, que, por sua pouca idade, seria pessoa mais intimidável e mais vulnerável às suas investidas.

Assim, elevo a pena em 1/8 e a fixo em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes. Assim, mantenho a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, há a causa de aumento do art. 157, §2º, II, CP, pelo concurso de agentes, que proporcionou aos roubadores a segurança de que haveria um incremento da grave ameaça, perante o adolescente, justamente pelo número de agentes maiores atuando no assalto.

Assim, a reprovabilidade da conduta é aumentada neste caso concreto, o que enseja a majoração da pena em 1/3.

Por isso, a pena resta fixada em 6 anos e 14 dias-multa, reprimenda que se aplica a cada um dos crimes de roubo praticados contra os dois adolescentes.

Além disso, o crime foi praticado na modalidade tentada e, portanto, a pena deve ser reduzida em 1/2 (metade).

Opera-se a redução nesse quantum uma vez que os acusados estavam na metade do iter criminis, pois embarcaram no ônibus atrás da vítima para continuar com as ameaças visando ao roubo, mas não conseguiram e a vítima reagiu, havendo concurso policial posterior. Logo, não atingiu o réu o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, mas chegou a estágio intermediário do caminho do crime.

Assim, resta a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 7 dias-multa, pena esta que torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias.

b) Acusado MARCOS ANASTÁCIO PEREIRA FERNANDES:

Na primeira fase, devem ser consideradas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Destaco que o réu ostenta Maus antecedentes (processo n. 0042448-86.2010.8.26.0050 - fls. 97/98), razão pela qual aumento a pena em 1/8.

Além disso, a reprovabilidade da conduta do acusado está acima da média, pois praticou o delito propositalmente contra estudantes adolescentes, que, por sua pouca idade, seriam pessoas mais intimidáveis e mais vulneráveis às suas investidas.

Assim, elevo a pena em mais 1/8, havendo um aumento total em 2/8, ou seja, 1/4, na primeira fase.

A pena base fica fixada em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência (autos nº 0034478-54.2018.8.26.0050 - Fls. 97), razão pela qual aumento a pena em 1/6. Não há atenuantes.

Assim, fixo a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, há a causa de aumento do art. 157, §2º, II, CP, pelo concurso de agentes, que proporcionou aos roubadores a segurança de que haveria um incremento da grave ameaça, perante o adolescente, justamente pelo número de agentes maiores atuando no assalto.

Assim, a reprovabilidade da conduta é aumentada neste caso concreto, o que enseja a majoração da pena em 1/3.

Por isso, a pena é fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Além disso, o crime foi praticado na modalidade tentada e, portanto, a pena deve ser reduzida em 1/2 (metade).

Opera-se a redução nesse quantum uma vez que os acusados estavam na metade do iter criminis, pois embarcaram no ônibus atrás da vítima para continuar com as ameaças visando ao roubo, mas não conseguiram e a vítima reagiu, havendo concurso policial

posterior. Logo, não atingiu o réu o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, mas chegou a estágio intermediário do caminho do crime.

Assim, resta a pena definitiva em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 9 dias-multa, pena esta que torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

O concurso a ser aplicado entre os dois crimes de roubo em concurso formal e o crime de roubo tentado é a continuidade delitiva, pois preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71, caput e parágrafo único, CP.

Assim, aplico o aumento de 1/6 sobre a pena resultante da aplicação do concurso formal mencionada acima.

a) Acusado ABNER HENRIQUE VICENTE FERREIRA:

A pena total fica em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 17 dias-multa.

b) Acusado MARCOS ANASTÁCIO PEREIRA FERNANDES:

A pena total fica em 9 anos e 26 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento de pena para ambos os réus, pelas circunstâncias judiciais e legais reconhecidas nesta sentença, bem como pela quantidade de pena (art. 33, §2º, "a" e §3º, CP).

Deixo de aplicar os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal aos condenados pela quantidade de pena e pelas circunstâncias judiciais e legais negativas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado ABNER HENRIQUE VICENTE FERREIRA ao cumprimento da pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 17 dias-multa, no piso, e o acusado MARCOS ANASTÁCIO PEREIRA FERNANDES ao cumprimento da pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 21 dias-multa, no piso, porque incurso, cada um dos acusados, no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, e artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Os acusados estão presos e não poderão recorrer em liberdade, porque efetivamente necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, evitando reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal, evitando que fujam, ante a pesada pena ora imposta.

Destaco, ainda, que o réu Abner foi preso em flagrante em 01 de março de 2022, pela prática de crime de furto de celular, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, as medidas cautelares não se mostraram suficientes, pois apenas 10 dias após, aparentemente, o réu voltou a se envolver na prática de delito patrimonial grave (fls. 130-134). Já o réu Marcos é reincidente e possui maus antecedentes (art. 33, §2º, "b", e §3º, CP).

Deixo fixar valor de reparação, pela ausência de pedido e pelo fato de as mercadorias terem sido devolvidas.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pelo princípio da isonomia quanto aos demais custodiados, porque não há como o juízo do conhecimento saber se houve o preenchimento dos requisitos subjetivos para a progressão de regime.

Comunique-se às vítimas, nos termos do artigo 201, § 2º do Código de Processo Penal, pessoalmente, observando-se que esse intento, de saber o conteúdo da sentença, foi expresso pelos adolescentes em Juízo.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, observada gratuidade de justiça eventualmente deferida pelo Juízo das Execuções, que tem mais elementos para analisar pleito nesse sentido.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, efetuem-se as anotações e comunicações necessárias, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD.

Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.I.C.

São Paulo, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA